

正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 刑法第36条にいう「急迫」とは、法益が侵害される危険が切迫していることをいい、被害の現在性を意味するものではない。
2. 刑法第36条にいう「不正」とは、違法であることを意味し、侵害が全体としての法秩序に反することをいう。
3. 刑法第36条にいう「権利」は個人的法益を指し、国家的法益や社会的法益は含まれない。
4. 侵害者に対する攻撃的な意思を有していたとしても、防衛の意思が認められる場合がある。
5. けんか闘争において正当防衛が成立するかどうかを判断するに当たっては、闘争行為中の瞬間的な部分の攻防の態様のみに着眼するのではなく、けんか闘争を全般的に観察することが必要である。

1 正しい

最判昭24.8.18。36条1項にいう「急迫」性の意義について、判例は、「『急迫』とは、法益の侵害が間近に押し迫ったことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味するのであつて、被害の現在性を意味するものではない。ただし、被害の緊迫した危険にある者は、加害者が現に被害を与えるに至るまで、正当防衛することを待たねばならぬ道理はないからである。」としている。

2 正しい

最判昭50.12.25。36条1項の「不正」とは違法を意味し、違法とは全体として法秩序に反することをいう。判例も、違法かどうかの判断に際して、「被告人らの各行為は、法秩序全体の見地からこれを見るときは、原判決の判示するその動機目的、その他諸般の事情を考慮に入れても、なお、到底許容されるものとはいひ難く、刑法上違法性を欠くものではないというべきである。」とする。

3 誤っている

最判昭24.8.18。36条1項にいう「権利」に個人的法益にとどまらず、国家的法益ないし公共的・社会的法益が含まれるかについて、判例は、「国民の安全利福の防衛に関する……かかる公益ないし国家的法益の防衛が、正当防衛として認められ得るか否かについては、これを否定する学説見解もないではないが、公共の福祉を最高の指導原理とする新憲法の理念から言っても、公共の福祉をも含めてすべての法益は防衛せらるべきであるとする刑法の理念から言っても、国家的、国民的、公共的法益についても正当防衛の許さるべき場合が存することを認むべきである。」としている。

4 正しい

最判昭50.11.28（百選I24事件）。侵害者に対して攻撃的な意思を有していた場合にも防衛の意思が認められるかにつき、判例は、「防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないので、これを正当防衛のための行為と評価することができる」とする。

5 正しい

最大判昭23.7.7。けんか闘争において正当防衛が成立するかどうかについて、判例は、「互に暴行し合ういわゆる喧嘩は、闘争者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一団の連続的闘争行為であるから、闘争の或る瞬間においては、闘争者の一方がもっぱら防禦に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあつても、闘争の全般からみては、刑法第36条の正当防衛の觀念を容れる余地がない場合がある。」としている。